

บทที่ ๔

คดีปกครองเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

๑. การควบคุมอาคาร

๑.๑ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการฟ้องเพิกถอนกฎ

๑.๑.๑ ข้อบัญญัติท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๒ เทศบัญญัติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ ข้อพิพาทเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

๑.๒.๑ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบรับแจ้งตามคำขอ

ขณะที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขออนุญาตก่อสร้างสถานบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ยังมิได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และยังมิได้มีการประกาศให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ในพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีขออนุญาตก่อสร้าง เทศบาลตำบลและนายกเทศมนตรีตำบลจึงไม่ใช่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ที่จะมียอำนาจในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตรวมทั้งออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร การที่นายกเทศมนตรีฯ ไม่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าตนไม่มีอำนาจหน้าที่และไม่ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่ถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ นายกเทศมนตรีตำบลปัว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อเป็นสถานบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว



ตั้งอยู่บนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๖๓๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลปัทวิ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริเวณพื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และไม่มีกฎกระทรวงผังเมืองรวมบังคับใช้ แต่เนื่องจากบริเวณที่ผู้ฟ้องคดีขออนุญาตก่อสร้างนั้นอยู่ในเขตชุมชนและใกล้สถานศึกษา จึงมีความจำเป็นต้องจัดเวทีประชาคมเพื่อให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจในการพิจารณาคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารสถานที่บริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือไม่ กลับสร้างขึ้นตอนโดยการจัดเวทีประชาคม ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงขอให้เลิกเล็งต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย โดยออกคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารสถานที่บริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายในเวลาที่ศาลกำหนด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ขออนุญาตก่อสร้างสถานบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตั้งอยู่บนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๖๓๘ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ไม่ปรากฏว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อใช้บังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ส่วนกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งบังคับใช้ในพื้นที่ตำบลปัทวิ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีขออนุญาตก่อสร้างสถานบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวนั้น ยังมิได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อใช้บังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และไม่มีมีการประกาศให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ใช่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ที่จะมีอำนาจในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตรวมทั้งออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารสถานที่บริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว และไม่ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าว จึงไม่ถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ทั้งนี้ เมื่อกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงมีอำนาจพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ที่ยื่นภายหลังจากกฎกระทรวงดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว เมื่อคำขออนุญาตก่อสร้างสถานบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว



ของผู้ฟ้องคดี ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ เป็นคำขอที่ได้ยื่นไว้ก่อนที่กฎกระทรวงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ คำขอดังกล่าวจึงไม่อาจถือเป็นคำขอที่ยื่นโดยชอบตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะต้องพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตแต่ประการใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๐๗/๒๕๖๓)

๑.๒.๒ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตโดยมิชอบ

กรณีที่มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือใบรับแจ้งการก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ก่อนที่จะมีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องอายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือดัดแปลงอาคารได้ต่อเมื่อเข้าหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขสองประการ คือ อาคารที่จะต่ออายุใบอนุญาตจะต้องก่อสร้างฐานรากทั้งหมดของอาคารแล้วเสร็จ หรือก่อสร้างหรือดัดแปลงโครงสร้างของอาคารไปแล้วเกินร้อยละสิบของพื้นที่อาคารที่ได้รับอนุญาต เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การก่อสร้างอาคารห้างสรรพสินค้าของผู้ร้องสอดได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายเฉพาะในพื้นที่จำนวน ๑๓.๖๔ ไร่ แต่ผู้ร้องสอดได้ดำเนินการในพื้นที่โดยมีการสร้างรั้วประมาณ ๑๐๐ เมตร ถมดินในพื้นที่บางส่วนประมาณ ๔ ไร่ และมีการตอกเสาเข็มประมาณ ๑๖ ต้น แล้วไม่มีการดำเนินการอย่างใดอีก จึงไม่อาจถือว่าเป็นการเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารและยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จที่จะได้รับการยกเว้นตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างให้แก่ผู้ร้องสอด ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างให้แก่ผู้ร้องสอดจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๖ ผู้ร้องสอดได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๙ ทวิ ต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลนาจักร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อก่อสร้างอาคารพาณิชย์ขนาด ๑ ชั้น ชั้นลอย ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ขนาดพื้นที่ ๑๐,๙๖๑ ตารางเมตร และป้ายโฆษณาจำนวน ๓ ป้าย โดยจะเริ่มก่อสร้างในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ เพื่อใช้เป็นห้างสรรพสินค้าบนเนื้อที่ดินจำนวน ๒๐.๑๔ ไร่ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกใบรับแจ้งเพื่อก่อสร้างอาคารก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน เลขที่ ๑/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓๐



เมษายน ๒๕๔๖ ตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก่ผู้ร้องสอด ต่อมา ผู้ร้องสอด ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๘ ขอต่อยายุไบบ้างแจ้งเพื่อก่อสร้างอาคารดังกล่าว เนื่องจากก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ต่อยายุไบบ้างแจ้งเพื่อก่อสร้างอาคาร โดยออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน เลขที่ ๔๗/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ขยายเวลาการก่อสร้างออกไปอีก ๑ ปี ให้แก่ผู้ร้องสอด ผู้ฟ้องคดี ทั้งห้าเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ตรวจสอบว่าผู้ร้องสอดได้ก่อสร้างอาคารแล้วหรือไม่ แต่ได้ต่อยายุไบบ้างแจ้งเพื่อก่อสร้างอาคาร โดยออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ ๔๗/๒๕๔๘ฯ ให้แก่ผู้ร้องสอดโดยไม่ชอบ ด้วยกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลทุ่งไธ้ง ตำบลแม่ยม ตำบลร่องพอง ตำบลทุ่งกวาว ตำบลป่าเมต ตำบลเหมืองหม้อ ตำบลโนเวียง ตำบลกาญจนา และตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ และตำบลเวียงทอง และตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้ร่วมกับบุคคลอื่นได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๙ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอให้ระงับการก่อสร้างและเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้แจ้งผลให้ทราบ และไม่ได้มีคำสั่งระงับการก่อสร้าง โดยยกเลิกเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามอำนาจหน้าที่ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน เลขที่ ๔๗/๒๕๔๘ฯ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อในขณะที่ผู้ร้องสอดขอต่อยายุไบบ้างแจ้งเพื่อก่อสร้าง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อยายุไบบ้างแจ้งให้ก่อสร้างออกไปอีก ๑ ปี นั้น กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๗ มีผลใช้บังคับ เป็นเหตุให้นับตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๗ ที่กฎกระทรวงดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา พื้นที่บริเวณที่ ๒ ซึ่งรวมถึงพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างอาคารห้างสรรพสินค้าของผู้ร้องสอด ต้องห้ามมิให้ก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกัน หรือหลายหลังเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่จะเข้าเงื่อนไขข้อ ๕ ของกฎกระทรวงดังกล่าว คือ จะต้องได้รับอนุญาตก่อสร้างหรือไบบ้างแจ้งการก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ แล้ว แต่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ก็สามารถที่จะก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตรได้ และเมื่อพิจารณาตามข้อ ๖/๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘)



ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๗ (พ.ศ. ๒๕๔๔)ฯ การที่จะถือว่าได้มีการก่อสร้างอาคาร อย่างน้อยจะต้องมีการเริ่มก่อสร้างฐานรากหรือมีการก่อสร้างอาคารไปบ้างแล้ว แต่ในส่วนของผู้ร้องสอดข้อเท็จจริงปรากฏ แต่เพียงว่า มีการสร้างรั้วชั่วคราวประมาณ ๑๐๐ เมตร ซึ่งในการสร้างรั้วเป็นเพียงการแสดงอาณาเขตพื้นที่ของตนเท่านั้น ยังมีอาจถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มก่อสร้างอาคาร ส่วนการถมดิน มีการถมดินในพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างเพียง ๔ ไร่ จากทั้งหมด ๒๐.๑๔ ไร่ จึงยังอาจถือได้ว่าการปรับพื้นที่ให้มีสภาพพร้อมที่จะก่อสร้างอาคาร และไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างอาคาร ส่วนการตอกเสาเข็มจำนวนประมาณ ๑๖ ต้น โดยที่จุดที่ตอกเสาเข็ม ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ๔ ไร่ ที่มีการถมดินไว้และจุดที่ตอกเสาเข็มก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างอาคารหลัก กรณีจึงยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารห้างสรรพสินค้า เช่นเดียวกัน ประกอบกับข้อเท็จจริงยังรับฟังได้อีกว่า การก่อสร้างรั้วชั่วคราว การถมดินและการตอกเสาเข็มดังกล่าวได้ดำเนินการก่อนที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ตำบลทุ่งไธ้ง ตำบลแม่มด ตำบลร่องฟอง ตำบลทุ่งกวาว ตำบลป่าเมต ตำบลเหมืองหม้อ ตำบลในเวียง ตำบลกาญจนา ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ และตำบลเวียงทอง ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๖ ซึ่งข้อกำหนดของประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้มีเนื้อหาสาระเช่นเดียวกับกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ร้องสอดได้มีการล้อมรั้ว ถมดิน และตอกเสาเข็มดังกล่าว มีเจตนาที่จะรักษาสถานีในการก่อสร้างอาคารตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารห้างสรรพสินค้า และยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จที่จะได้รับการยกเว้นไม่อยู่ในบังคับของข้อ ๕ ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่จะสามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ซึ่งเป็นกฎกระทรวงที่ใช้บังคับในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างให้แก่ผู้ร้องสอดแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างให้แก่ผู้ร้องสอดออกไปอีก ๑ ปี จนถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ตามใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอน เลขที่ ๔๗/๒๕๔๘ฯ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นเหตุให้การดำเนินการก่อสร้างอาคารห้างสรรพสินค้าของผู้ร้องสอดจนแล้วเสร็จ เป็นการก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก



เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และเป็นเหตุให้ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร เลขที่ ๐๐๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกให้แก่ผู้ร้องสอดเพื่อใช้เป็นอาคารห้างสรรพสินค้าไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องดำเนินการตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ กับการก่อสร้างอาคารห้างสรรพสินค้าของผู้ร้องสอดดังกล่าว แล้วแต่กรณีต่อไป พิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน เลขที่ ๔๗/๒๕๔๘ฯ ที่อนุญาตให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างอาคารห้างสรรพสินค้า โดยให้มีผลนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตเป็นต้นไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕๖/๒๕๖๔)

๑.๓ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

๑.๓.๑ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารโดยรุกล้ำที่สาธารณะ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓.๒ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารโดยเว้นระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สาธารณะโดยฝ่าฝืนกฎหมาย

ผู้ร้องสอดก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยไม่มีการเว้นระยะห่างระหว่างอาคาร ถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อข้อ ๕๐ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ดำเนินการออกคำสั่งทางปกครองให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีพักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ ๑/๕ ซอยท่าเรือ ถนนชาน้ำ ตำบลปากพั่น อำเภอปากพั่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่นาย ว. (ผู้ร้องสอด) เจ้าของบ้านข้างเคียงเลขที่ ๑/๗ ก่อสร้างอาคารโดยไม่เสนอ



แบบแปลนและไม่ได้รับอนุญาตจากนายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง (ผู้ถูกฟ้องคดี) และไม่เว้นระยะห่างระหว่างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ร้องเรียนไปยังผู้ถูกฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้นัดหมายให้ผู้ฟ้องคดีกับผู้ร้องสอดมาเจรจากัน แต่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการกับผู้ร้องสอดตามระเบียบและกฎหมายต่อไป แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการให้ผู้ร้องสอดแก้ไขอาคารให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยืนยันว่า อาคารเลขที่ ๑/๗ ของผู้ร้องสอดก่อสร้างชิดเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ได้เว้นระยะห่างระหว่างอาคารตามข้อ ๕๐ วรรคสองของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แม้ผู้ร้องสอดจะกล่าวอ้างว่าผู้ฟ้องคดียินยอมให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างอาคารชิดผนังอาคารของผู้ฟ้องคดี เพราะผู้ฟ้องคดีไม่ได้คัดค้านการก่อสร้างตั้งแต่ต้นจนก่อสร้างแล้วเสร็จก็ตาม แต่เมื่ออาคารของผู้ฟ้องคดีและผู้ร้องสอดปลูกสร้างในที่สาธารณะโดยทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ร้องสอดต่างก็ไม่มีเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน จึงไม่ใช่กรณีที่สามารถได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงให้ก่อสร้างชิดผนังอาคารได้ ข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องสอดในประเด็นนี้จึงฟังไม่ขึ้น ดังนั้น การก่อสร้างอาคารของผู้ร้องสอดจึงขัดกับข้อ ๕๐ วรรคสอง ของกฎกระทรวง เดียวกัน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ออกคำสั่งทางปกครองให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารเลขที่ ๑/๗ ระงับการกระทำดังกล่าว หรือดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารดังกล่าวให้ถูกต้องหรือสั่งให้รื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างโดยไม่ถูกต้องในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หรือดำเนินการหรือจัดให้มีการรื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างโดยไม่ถูกต้องดังกล่าว ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ แล้วแต่กรณี ด้วยเหตุนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย กรณีผู้ร้องสอดก่อสร้างอาคารเลขที่ ๑/๗ ซอยท่าเรือ ถนนชายน้ำ ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ชิดแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยไม่เว้นระยะห่างระหว่างอาคาร แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการออกคำสั่งทางปกครองให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ดังกล่าวแต่ประการใด การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ พิกษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ตามลำดับกรณีการก่อสร้างอาคารของผู้ร้องสอด เลขที่ ๑/๗ ซอยท่าเรือ ถนนชายน้ำ ตำบลปากพนัง



อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่าฝืนข้อ ๕๐ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗/๒๕๖๔)

๑.๓.๓ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารในบริเวณที่มีการกำหนดห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือกฎหมายอื่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓.๔ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ โดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกรณีอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ ข้อพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารดำเนินการ

๑.๔.๑ กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้

การก่อสร้างบ้านพักอาศัยที่มีลักษณะเป็นโครงไม้สังกะสีชั้นเดียว ในที่ดินของบุคคลอื่นหลังจากที่ได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างอาคารดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือมีการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ ถือเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจพิจารณาสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารระงับการกระทำและห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร หรือบริเวณที่มีการกระทำความดังกล่าวตามมาตรา ๔๐ หรือสั่งให้เจ้าของอาคารยื่นคำขออนุญาต หากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ตามมาตรา ๔๑ หรือสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารรื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ หากเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ หรือเจ้าของอาคารมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองปลูกสร้างบ้านมีลักษณะเป็นโครงไม้สังกะสีชั้นเดียวเพื่อใช้เป็นบ้านพักอาศัย ในที่ดินมีโฉนดของบริษัท พ. จำกัด ซึ่งอยู่ที่ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ต่อมา เจ้าหน้าที่ของนายกเทศมนตรีนครรังสิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตรวจสอบพบว่า บ้านของผู้ฟ้องคดีทั้งสองดังกล่าวก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และอาจเป็นภัยอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ระวังการใช้โครงไม้สังกะสีชั้นเดียว ขนาด ๑๐ เมตร x ๑๐ เมตร ทั้งหมด จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ห้ามใช้โครงไม้สังกะสีชั้นเดียวขนาด ๑๐ เมตร x ๑๐ เมตร ทั้งหมด และให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับคำสั่ง และในวันเดียวกันนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ระวังการใช้โครงไม้สังกะสีชั้นเดียว ขนาด ๕ เมตร x ๑๖ เมตร ทั้งหมด จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ห้ามใช้โครงไม้สังกะสีชั้นเดียว ขนาด ๕ เมตร x ๑๖ เมตร ทั้งหมด และให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับคำสั่ง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ได้รับการวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า อาคารบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีทั้งสองตั้งอยู่ที่ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และมีการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ดังนั้น การก่อสร้างอาคารดังกล่าวจึงอยู่ในบังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ตามพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตสุขาภิบาลคลองหลวง อำเภอคลองหลวง และเขตสุขาภิบาลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๓๐ เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองก่อสร้างอาคารพิพาทโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ จึงเป็นการก่อสร้างอาคารโดยฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ระวังการใช้โครงไม้สังกะสีชั้นเดียว ขนาด ๑๐ เมตร x ๑๐ เมตร ทั้งหมด ห้ามใช้โครงไม้สังกะสีชั้นเดียว ขนาด ๑๐ เมตร x ๑๐ เมตร ทั้งหมด และให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และมีคำสั่งให้สั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ระวังการใช้โครงไม้สังกะสีชั้นเดียว ขนาด ๕ เมตร x ๑๖ เมตร ทั้งหมด ห้ามใช้โครงไม้สังกะสีชั้นเดียว ขนาด ๕ เมตร x ๑๖ เมตร ทั้งหมด และให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงเป็นการดำเนินการ



ตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ทั้งนี้ คำสั่งดังกล่าวได้มีการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบแล้วว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ก่อสร้างอาคารโครงไม้สังกะสีชั้นเดียว ขนาดเท่าใด ก่อสร้างบริเวณไหน และเป็นการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และอ้างอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ รวมทั้งมีการพิจารณาแล้วว่า อาคารของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และอาจเป็นภัยอันตรายต่อสุขภาพชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน และการกระทำดังกล่าวไม่ขัดกับกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๘ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ จึงถือได้ว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นไปตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แล้ว คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามนัยมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ได้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๑/๒๕๖๔)

การก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ติดต่อหรือใกล้ชิดกับทางสาธารณประโยชน์ ถือเป็นการก่อสร้างอาคารที่จะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ ก่อน จึงดำเนินการก่อสร้างได้ตามนัยมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ติดต่อหรือใกล้ชิดกับทางสาธารณประโยชน์โดยมิได้ดำเนินการดังกล่าว เป็นกรณีที่สามรถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างรั้วพืพาท และคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างรั้วดังกล่าว จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ แล้ว และกรณีเช่นนี้เป็นการใช้อำนาจทางปกครองเพื่อบังคับเอาากับผู้ที่กระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายอย่างแจ้งชัด เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจออกคำสั่งทางปกครองประเภทนี้โดยไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๖๐ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ยาว ๕๗ เมตร สูง ๒ เมตร เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกของที่ดิน ซึ่งเป็นบริเวณที่ติดต่อกับถนนที่ใช้เป็นทางเข้าออกสู่ถนนศรีจันทร์ หลังจากนั้น นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น



(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งจำนวน ๓ คำสั่ง ได้แก่ คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างรั้วพินาท และคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างรั้วดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งทั้งสองฉบับดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยเห็นว่า รั้วพินาทไม่เป็นอาคารตามมาตรา ๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เนื่องจากไม่ได้ติดต่อกับทางสาธารณะ แต่ทางดังกล่าวเป็นทางส่วนบุคคลของผู้ฟ้องคดีและญาติ แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งสองคำสั่ง รวมทั้งเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า บิดาและมารดาของผู้ฟ้องคดีได้สละและอุทิศที่ดินบางส่วนเป็นทางสาธารณประโยชน์โดยปริยายแล้วตั้งแต่ในขณะแบ่งแยกที่ดินออกเป็นแปลงย่อยที่ดินพินาทจึงตกเป็นทางสาธารณประโยชน์อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้งนี้สภาพความเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินดังกล่าวย่อมไม่สูญสิ้นไปเพราะการไม่ได้มีบุคคลใดเข้าใช้ประโยชน์ หรือแม้ผู้ฟ้องคดีจะได้หวงกันและครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ดินพินาทซึ่งเป็นทางสาธารณประโยชน์มาโดยตลอด ก็หาทำให้ทางบริเวณดังกล่าวตกไปเป็นทางส่วนบุคคลของผู้ฟ้องคดีแต่ประการใด ดังนั้น รั้วพินาทซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างขึ้นเพื่อแสดงแนวเขตที่ดินทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตก จึงต้องรับฟังเป็นยุติว่าเป็นการก่อสร้างติดต่อกับหรือใกล้ชิดกับทางสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ รั้วพินาทถือเป็นอาคารตามนิยามในมาตรา ๔ (๒) ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ ก่อน จึงดำเนินการก่อสร้างได้ตามนัยมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างรั้วดังกล่าวซึ่งถือเป็นอาคารโดยไม่ได้ขออนุญาตต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อนที่จะทำการก่อสร้าง กรณีจึงเป็นการก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารระงับการสร้างหรือรื้อถอนออกไปได้อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และโดยที่กรณีที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างรั้วพินาทโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ เป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าของอาคารยื่นคำขออนุญาตให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการยื่นขออนุญาตต่อผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๑ ภายใน ๓๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง ซึ่งเป็นระยะเวลามากกว่าระยะเวลาขั้นต่ำ ที่กฎหมายกำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้เวลาแก่ผู้ได้รับคำสั่งในการปฏิบัติตามคำสั่ง อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยมีเพียงแต่คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ให้ถูกต้องเท่านั้น นอกจากนี้ แม้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งสองคำสั่งจะมีสถานะเป็นคำสั่ง ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่ในการก่อสร้างรั้วพินาท นั้น ผู้ฟ้องคดีจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ เมื่อผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ยื่นขออนุญาตต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ก่อสร้างรั้วพินาท ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิตามกฎหมายที่จะได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ และการใช้อำนาจของเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นดังกล่าว เป็นการใช้อำนาจทางปกครองเพื่อบังคับเอา กับผู้ที่กระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติ แห่งกฎหมายอย่างแข็งขัน เพื่อให้บุคคลผู้นั้นกระทำการตามที่กฎหมายกำหนดหรือละเว้น การกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจออกคำสั่งทางปกครอง ประเภทนี้โดยไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครองฯ ดังนั้น การใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการออกคำสั่ง ดังกล่าว จึงเป็นการกระทำโดยถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญ ที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น และชอบด้วยกฎหมายแล้ว ด้วยเหตุนี้ คำวินิจฉัยของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๗/๒๕๖๔ ที่ อ.๘๗๙/๒๕๖๓ ที่ อ.๙๙๖/๒๕๖๓ ที่ อ.๑๑๙๔/๒๕๖๓ ที่ อ.๑๒๘๗/๒๕๖๓ และที่ อ.๑๓๙๘/๒๕๖๓ วินิจฉัย แนวทางเดียวกัน)

๑.๔.๒ กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้ถูกต้องได้หรือเจ้าของอาคารมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงของ เจ้าพนักงานท้องถิ่น

การวินิจฉัยว่าสิ่งใดเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม อาคาร ย่อมมีผลให้การดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งนั้นอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคาร ซึ่งเป็นบทกฎหมายในทางจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ดังนั้น จึงไม่อาจวินิจฉัยหรือแปลความโดยไม่เคร่งครัดเพื่อให้ครอบคลุมไปถึงสิ่งต่าง ๆ ที่นอกเหนือเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ ดังนั้น เมื่อชুমแมงคำพิพากษามีลักษณะเป็น



โครงเหล็ก มีล้อเลื่อน ขนาดประมาณ ๑.๒๐ x ๑.๕๐ เมตร สูงประมาณ ๒.๖๐ เมตร จำนวน ๑๕๐ หลัง วางเรียงติดต่อกันเป็นกลุ่ม ๆ บริเวณพื้นถนนเพื่อใช้ในการวางจำหน่ายสินค้าเพียงชั่วระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยซุ้มแผงค้าพิพาทมิได้ติดตรึงกับพื้นถนนอย่างถาวร สามารถเข็นหรือเคลื่อนย้ายได้ ซุ้มแผงค้าพิพาทจึงไม่เข้าลักษณะเป็นอาคารตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างพร้อมติดตั้งอาคารโครงเหล็ก คำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีหรือบุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณของอาคารดังกล่าว และคำสั่งให้รื้อถอนอาคารทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ (๑) (๒) และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ จึงเป็นการกระทำนอกเหนืออำนาจ อันมีผลให้เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับสัมปทานสิทธิการเช่าลงทุนต่างตอบแทนเพื่อปรับปรุงและสร้างอาคารพาณิชย์ใหม่พร้อมพัฒนาที่ดินและจัดระเบียบภายในพื้นที่เวียงคลองถมจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในที่ดินมีโฉนด และได้ดำเนินการติดตั้งซุ้มแผงค้าโครงเหล็กมีล้อเลื่อน ขนาดประมาณ ๑.๒๐ x ๑.๕๐ เมตร สูงประมาณ ๒.๖๐ เมตร จำนวน ๑๕๐ หลัง บริเวณพื้นถนนจึงเจริญพาณิชย์ของโครงการเพื่อวางจำหน่ายสินค้า แต่เจ้าหน้าที่ของผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีติดตั้งซุ้มแผงดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีคำสั่งจำนวน ๓ คำสั่ง ได้แก่ คำสั่งให้ระงับการก่อสร้างพร้อมติดตั้งอาคารโครงเหล็ก จำนวน ๑๕๐ หลัง จนกว่าจะได้รับอนุญาต หรือได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น คำสั่งห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณของอาคารดังกล่าวทั้งหมด และคำสั่งให้รื้อถอนอาคารทั้งหมดให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งทั้งสามดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) แต่ได้รับการวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทั้งสามคำสั่ง และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีจัดทำซุ้มแผงค้าโครงเหล็กมีล้อเลื่อนขนาดประมาณ ๑.๒๐ x ๑.๕๐ เมตร สูงประมาณ ๒.๖๐ เมตร จำนวน ๑๕๐ หลัง และนำเอาซุ้มแผงค้าโครงเหล็ก

ดังกล่าวมาจัดวางเรียงติดต่อกันเป็นกลุ่ม ๆ บริเวณพื้นถนนจึงเจริญพาณิชย์ของโครงการเพื่อใช้ในการวางจำหน่ายสินค้า ซึ่งซุ้มแผงค้าที่มีการติดตั้งล้อเลื่อนในแต่ละซุ้มมีลักษณะเป็นอุปกรณ์ที่จัดทำขึ้นแยกต่างหากจากกัน ดังนั้น จึงมีการเจาะรูยึดซุ้มแต่ละซุ้มด้วยการสลักเกลียวต่อเนื่องเป็นแถวยาว แถวละ ๘ ซุ้ม โดยเว้นระยะห่างพอที่จะเดินผ่านช่องระหว่างซุ้มแผงค้าได้ บุคคลสามารถเข้าไปใช้สอยสำหรับเก็บและขายสินค้าในลักษณะเชิงพาณิชย์กรรมได้ แต่ก็เป็นเพียงการยึดติดเพื่อมิให้มีการไหลเลื่อน ซึ่งเป็นการป้องกันปัญหาอื่น ๆ และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเท่านั้น เมื่อพิจารณาสภาพการใช้ประโยชน์ซุ้มแผงค้าพิพาทแล้วเห็นได้ว่า มีลักษณะพื้นที่จำกัดแคบ ไม่เพียงพอที่จะให้ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการสามารถเข้าไปด้านในซุ้ม อย่างมากที่สุดไม่เกิน ๒ คน และได้เพียงชั่วระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง อีกทั้ง ซุ้มแผงค้าพิพาทมิได้ติดตรึงกับพื้นถนนของโครงการเว็จคลองถมอย่างถาวร สามารถเข็นหรือเคลื่อนย้ายได้ ในประการสำคัญ การจะวินิจฉัยว่าสิ่งใดเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ย่อมมีผลให้การดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งนั้นอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เช่น การที่ต้องขออนุญาตหรือมีการแจ้ง กรณีเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายมีอำนาจออกคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างให้แก้ไขให้ถูกต้อง ห้ามใช้ประโยชน์หรือให้รื้อถอนสิ่งนั้น ซึ่งเป็นบทกฎหมายในทางจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ดังนั้น จึงไม่อาจวินิจฉัยหรือแปลความโดยไม่เคร่งครัดเพื่อให้ครอบคลุมไปถึงสิ่งต่าง ๆ ที่นอกเหนือเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ ดังนั้น จึงไม่อาจถือว่าซุ้มแผงค้าพิพาทในคดีนี้เข้าลักษณะเป็นอาคารตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ การติดตั้งซุ้มแผงค้าพิพาทจึงไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๑ ทวิ และมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างพร้อมติดตั้งอาคารโครงเหล็ก จำนวน ๑๕๐ หลัง คำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีหรือบุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณของอาคารดังกล่าว และคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ (๑) (๒) และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ จึงเป็นการกระทำนอกเหนืออำนาจ อันมีผลให้เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริงในการพิจารณาอย่างเดียวกันกับการออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งได้ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กรณีจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างพร้อมติดตั้งอาคารโครงเหล็ก จำนวน ๑๕๐ หลัง คำสั่งที่ห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีหรือบุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณของอาคารดังกล่าว และคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน



๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง รวมทั้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๘๘/๒๕๖๓)

ขณะที่มีการก่อสร้างประตูเหล็กที่พิพาท ยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมก่อสร้างอาคารในพื้นที่ดังกล่าว การก่อสร้างประตูเหล็กพิพาทจึงไม่ต้องยื่นขออนุญาตปลูกสร้างต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ และเมื่อประตูเหล็กพิพาทได้ก่อสร้างมาก่อนที่จะมีการแบ่งแยกที่ดินออกเป็นแปลงย่อย จำนวน ๘ แปลง และก่อนที่จะแบ่งหักและกันที่ดินบางส่วนให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ที่ดินแปลงแบ่งแยกแต่ละแปลงใช้เป็นทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะภายนอก การแบ่งหักและกันที่ดินบางส่วนใช้เป็นทางสาธารณประโยชน์จึงเป็นการยกให้เฉพาะที่ดิน หาได้รวมถึงประตูเหล็กพิพาทด้วยไม่ แม้สภาพปัจจุบันประตูเหล็กพิพาทจะตั้งขวางหรือปิดกั้นทางสาธารณประโยชน์ทำให้บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในทางดังกล่าวได้ กรณีก็หาเป็นการก่อสร้างอาคารโดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงหาไม่อาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ครอบครองประตูเหล็กพิพาทต่อเนื่องมาจากบิดาและมารดาของผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างประตูเหล็กดังกล่าวตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนประตูเหล็กพิพาทตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันได้แต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๖๐ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผู้ฟ้องคดีได้รับให้ที่ดินมาจากนางมารดาของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๒๗ ต่อมา นาย ส. ได้ยื่นคำร้องต่อเทศบาลนครขอนแก่น ขอให้รื้อถอนประตูเหล็กซึ่งก่อสร้างอยู่บนทางติดกับบ้านและที่ดินของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากก่อสร้างปิดกั้นทางสาธารณประโยชน์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตรวจสอบแล้วได้มีคำสั่งที่ ขก ๕๒๐๔/๑๙๓๙ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างประตูเหล็กพิพาท ขนาดกว้างประมาณ ๔ เมตร สูง ๒.๕ เมตร ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และคำสั่ง ที่ ขก ๕๒๐๔/๑๙๔๐ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนประตูเหล็กดังกล่าว ให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๕ วัน นับแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งทั้งสองฉบับดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการ



ส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดขอนแก่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งสองคำสั่งดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ศาลรับฟังข้อเท็จจริงว่า ทางซึ่งเป็นที่ตั้งประตูเหล็กพินาทเป็นทางสาธารณประโยชน์ (โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๗/๒๕๖๔ หน้า ๕๑๖-๕๑๘ ซึ่งวินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

ข้อเท็จจริงฟังต่อไปได้ว่า ผู้ฟ้องคดีรับว่า บิดาของผู้ฟ้องคดีก่อสร้างประตูเหล็กพินาทมาตั้งแต่ในขณะที่บริเวณดังกล่าวยังคงเป็นที่ดินแปลงใหญ่ผืนเดียว ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่จะแบ่งที่ดินออกเป็นแปลงย่อย จำนวน ๘ แปลง และแบ่งหักที่ดินบางส่วนเป็นทางสาธารณประโยชน์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ทั้งนี้ แม้จะไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่ชัดเจนว่าบิดาของผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างประตูเหล็กพินาทเมื่อปี พ.ศ.ใด แต่ก็ฟังได้ว่าย่อมไม่ช้าไปกว่าวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗ ซึ่งเป็นวันที่เจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดที่ดินทั้งแปดแปลงให้แก่บิดาและมารดาของผู้ฟ้องคดี ซึ่งในขณะนั้นพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ ยังไม่มีผลใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น (เขตการปกครองในขณะนั้น) ดังนั้น ที่ดินที่แบ่งหักจึงเป็นทางสาธารณประโยชน์ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗ ส่วนประตูเหล็กพินาทเป็นทรัพย์สินของบิดาและมารดาของผู้ฟ้องคดีซึ่งได้ก่อสร้างมาก่อนที่จะมีการแบ่งแยกที่ดินออกเป็นแปลงย่อย และก่อนที่จะแบ่งหักและกันที่ดินบางส่วนให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ และการแบ่งหักและกันที่ดินบางส่วนให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ก็เพื่อให้ที่ดินแปลงแบ่งแยกแต่ละแปลงใช้เป็นทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะภายนอก จึงย่อมเป็นการยกให้เฉพาะที่ดินซึ่งเป็นทางในส่วนที่บิดาและมารดาของผู้ฟ้องคดีมีกรรมสิทธิ์เท่านั้น หากได้รวมถึงประตูเหล็กพินาทซึ่งได้ก่อสร้างเพื่อแสดงอาณาเขตที่ดินของตนและเพื่อป้องกันอันตรายจากบุคคลภายนอกด้วยไม่ ทั้งนี้ แม้สภาพปัจจุบันจะปรากฏว่า ประตูเหล็กพินาทจะตั้งขวางหรือปิดกั้นทางสาธารณประโยชน์ ทำให้บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในทางดังกล่าวได้ แต่เมื่อการก่อสร้างประตูเหล็กพินาทนี้เป็นการก่อสร้างในขณะที่ที่ดินดังกล่าวยังไม่ได้เป็นทางสาธารณประโยชน์ จึงมิใช่การก่อสร้างอาคารโดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงหาได้มีอำนาจดำเนินการสั่งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ครอบครองประตูเหล็กพินาทต่อเนื่องมาจากบิดาและมารดาของผู้ฟ้องคดี ระงับการก่อสร้างประตูเหล็กดังกล่าวตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนประตูเหล็กพินาทตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างประตูเหล็กที่ปิดกั้นทางสาธารณประโยชน์ และคำสั่งให้



ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนประตูเหล็กดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ขก ๕๒๐๔/๑๙๓๙ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และคำสั่งที่ ขก ๕๒๐๔/๑๙๔๐ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยให้มีผลย้อนหลังไปนับแต่วันที่ออกคำสั่งดังกล่าว และให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๓๑/๒๕๖๓)

กรณีการต่อเติมอาคารด้วยการสร้างเป็นกันสาดมีลักษณะเป็นโครงเหล็กติดอยู่กับหลังคาในลักษณะถาวร ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ อันมีลักษณะเป็นอาคารตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อกันสาดพิพาทก่อสร้างยื่นล้ำเข้ามาบนถนนซึ่งเป็นภาระจำยอมโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารให้ถูกต้องและยื่นขอรับใบอนุญาตตัดแปลงอาคาร และคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารโดยอาศัยฐานจากคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้รับการร้องเรียนว่าอาคารพาณิชย์ของผู้ฟ้องคดีมีการต่อเติมอาคารยื่นล้ำเข้ามาบนถนนสาธารณะ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ และผลการตรวจสอบปรากฏว่าอาคารพิพาทมีการต่อเติมลักษณะเป็นกันสาดโครงเหล็กหลังคาสังกะสี ขนาด ๓.๕๐ x ๓.๕๐ เมตร สูง ๓ เมตร ยื่นล้ำเข้ามาบนถนนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ผู้อำนวยการเขตราชเทวี ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งเลขที่ กท ๗๑๐๓/๖๔๘๘ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการต่อเติมอาคารพิพาทจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น คำสั่งเลขที่ กท ๗๑๐๓/๖๔๘๘ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีหรือบุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณอาคารทั้งหมดของอาคาร และคำสั่งเลขที่ กท ๗๑๐๓/๖๔๘๐ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอใบอนุญาตต่อเติมอาคารพิพาทให้ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่



ได้รับคำสั่ง ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายในเวลาที่กำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งเลขที่ กท ๗๑๐๓/๗๖๕๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนกันสาดโครงเหล็กหลังคาสังกะสีที่พิพาทให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง ต่อมาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า กรณีการต่อเติมอาคารของผู้ฟ้องคดีเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอใบอนุญาตต่อเติมอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาดำเนินการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนส่วนต่อเติมอาคารพิพาทให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เลขที่ กท ๗๑๐๓/๖๔๘๘๙ คำสั่งเลขที่ กท ๗๑๐๓/๖๔๘๘๙ คำสั่งเลขที่ กท ๗๑๐๓/๗๖๕๙ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กันสาดที่ผู้ฟ้องคดีต่อเติมนั้นมีลักษณะเป็นโครงเหล็กติดอยู่กับหลังคาในลักษณะถาวร และไม่สามารถเก็บพับได้ ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ จึงถือเป็นอาคารตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และเมื่อพิจารณาสำเนาโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๕๕ เลขที่ดิน ๓๗๐ รูปแผนที่ (ใบต่อ) ปรากฏว่านาย ก. เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าวได้มีการแบ่งที่ดินออกเป็นแปลงย่อยจำนวน ๔๕ แปลง และแบ่งที่ดินส่วนหนึ่งมีลักษณะเป็นแนวยาวอยู่กึ่งกลางระหว่างที่ดินแปลงย่อยทั้งสองฝั่งซึ่งเชื่อมต่อกับถนนซอยเพื่อประโยชน์เป็นถนนสำหรับใช้เป็นทางเข้าออกของผู้อยู่อาศัยในโครงการ อันถือได้ว่าเป็นการจัดที่ดินเพื่อการสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์แก่ผู้พักอาศัยในโครงการ อันมีลักษณะเป็นการจัดสรรที่ดินตามข้อ ๑ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น และตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร เมื่อผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างต่อเติมเป็นกันสาดโครงเหล็กหลังคาสังกะสี ขนาด ๓.๕๐ x ๓.๕๐ เมตร สูง ๓ เมตร ยื่นล้ำเข้ามาบนถนนซึ่งเป็นภาระจำยอมโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการรื้อถอนได้ทันที การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่า การต่อเติมกันสาดโครงเหล็กหลังคาสังกะสียื่นล้ำเข้าไปบนถนนส่วนบุคคลของผู้ฟ้องคดี เป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ จึงได้มีคำสั่งเลขที่ กท ๗๑๐๓/๖๔๙๐ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องและยื่นขอรับใบอนุญาต



ดัดแปลงอาคารภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อาศัยคำสั่งดังกล่าวมาเป็นเหตุในการออกคำสั่งเลขที่ กท ๗๑๐๓/๗๖๕๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนกันสาดโครงเหล็กหลังคาสังกะสี จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำวินิจฉัยเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คำสั่งเลขที่ กท ๗๑๐๓/๖๔๙๐ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และคำสั่งเลขที่ กท ๗๑๐๓/๗๖๕๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว สำหรับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒๒ เลขที่ กท ๗๑๐๓/๖๔๘๘๗ เลขที่ กท ๗๑๐๓/๖๔๘๘๗ และเลขที่ กท ๗๑๐๓/๗๖๕๙๗ นั้น ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๘/๒๕๖๔)

การก่อสร้างอาคารในคลองสาธารณะโดยไม่ได้ออกอนุญาตใช้ที่ดิน ต่อหน่วยงานทางปกครองที่รับผิดชอบดูแลรักษาลongดังกล่าวโดยชอบด้วยขั้นตอนของกฎหมายก่อนตามข้อ ๔๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ย่อมเป็นกรณีที่ไม้อาจยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งจำนวน ๓ คำสั่ง ได้แก่ คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารพิพาท คำสั่งห้ามผู้ฟ้องคดีใช้อาคารพิพาท และคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาททั้งหมดให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้อำนาจคำสั่งดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยมาตรา ๔๐ (๑) (๒) (๓) และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และการที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยอาศัยข้อเท็จจริงอย่างเดียวกัน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีก่อสร้างบ้านไม้ใต้ถุนสูง เลขที่ ๒๕ ขนาด ๖ x ๖ เมตร บนที่ดินด้านทิศตะวันตกของโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๑๕๘๘ ตำบลประชาธิปไตย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นของบริษัท ส. จำกัด ตามสำเนาโฉนดที่ดินเลขที่ดังกล่าว ระบุอาณาเขตด้านทิศตะวันตกจดคลองสาธารณะประโยชน์ ต่อมา บริษัท ส. จำกัด ได้ฟ้องขับไล่ผู้ฟ้องคดีและให้รื้อถอนบ้านออกจากที่ดินแปลงโฉนดที่ดินดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงรื้อถอนบ้านและปลูกสร้างบ้านไม้ใต้ถุนสูงขึ้นใหม่ห่างจากแนวโฉนดที่ดินดังกล่าว ประมาณ ๓ เมตร หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของนายกเทศมนตรีนครรังสิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตรวจพบว่า ผู้ฟ้องคดีก่อสร้าง



อาคารไม้ใต้ถุนสูงรुक้าที่ริมคลองสาธารณประโยชน์ ซึ่งอยู่ติดกับแนวเขตที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๑๕๘๘ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งจำนวน ๓ คำสั่งถึงผู้ฟ้องคดี ได้แก่ คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารไม้ใต้ถุนสูงที่รูก้าที่สาธารณะทั้งหมด คำสั่งห้ามผู้ฟ้องคดีใช้อาคารไม้ใต้ถุนสูงที่ก่อสร้างรูก้าที่สาธารณะทั้งหมด และคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารไม้ใต้ถุนสูงที่ก่อสร้างรูก้าที่สาธารณะทั้งหมดให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ได้รับการวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทั้งสามคำสั่งดังกล่าวและห้ามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้ามายุ่งเกี่ยวกับบ้านของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า อาคารไม้ใต้ถุนสูง ขนาด ๖ x ๖ เมตรของผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอยู่ในบริเวณคลองสาธารณประโยชน์ถัดจากโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๑๕๘๘ ซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแลรักษาของกรมชลประทานต่งนั้น ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะก่อสร้างอาคารในคลองสาธารณะจึงต้องขออนุญาตจากกรมชลประทานเสียก่อน ทั้งนี้ ตามข้อ ๔๐ ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับหากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะก่อสร้างอาคารก็ชอบที่จะยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นเสียก่อน ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ขออนุญาตใช้ที่ดินต่อกรมชลประทานโดยชอบด้วยขั้นตอนของกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เช่นกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจตามมาตรา ๔๐ (๑) (๒) (๓) และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ในการมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการกระทำดังกล่าว มีคำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการกระทำดังกล่าว และจัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามนั้นไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณดังกล่าว และพิจารณามีคำสั่งตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีคำสั่ง และมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาททั้งหมดภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งที่ ปท ๕๒๑๐๓/๒๓๙๒ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารพิพาท คำสั่งที่ ปท ๕๒๑๐๓/๒๓๙๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ห้ามผู้ฟ้องคดีใช้อาคารพิพาท และคำสั่งที่ ปท ๕๒๑๐๓/๒๓๙๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาททั้งหมดให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้มีคำสั่งดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

